

1500259-44.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO DE FRANCA HELENE

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... manuscritas com a contabilidade do tráfico e R\$ 4,00 em espécie.

Indagado acerca dos objetos e entorpecentes, o acusado teria confessado a prática do tráfico, porém, em solo policial preferiu o silêncio.

Notificado o acusado, fora apresentada defesa prévia a fls. 118/119 e recebida a denúncia em 27 de maio de 2022 (fls. 121/124).

Durante a instrução, foram inquiridas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500259-44.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500259-44.2022.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. EDUARDO DE FRANCA HELENE

Vistos.

LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 9h15, na avenida dos Evangélicos, altura do número 601, Campo dos Alemães, em São José dos Campos, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, estaria trazendo consigo 270 porções de cocaína, 121 porções de crack, subproduto da cocaína, e 77 porções de maconha, conforme auto de exibição e apreensão, fotografias, auto de constatação de substância

entorpecente e exame químico-toxicológico.

Segundo consta, o denunciado estaria ocupando um ponto de venda de drogas estabelecido no local dos fatos, onde ele aguardava os compradores, trazendo consigo, dentro de uma sacola, centenas de porções de maconha, de crack e de cocaína fracionadas, embaladas e prontas para a venda no varejo. Nisso, ao perceber a aproximação de guardas municipais, Luciano teria fugido correndo, tendo sido alcançado poucos metros à frente. Em revista pessoal, dentro da sacola que o denunciado trazia à mão, os guardas municipais teriam apreendido 270 porções de cocaína, 121 porções de crack e 77 porções de maconha, além de uma folha contendo anotações manuscritas com a contabilidade do tráfico e R\$ 4,00 em espécie.

Indagado acerca dos objetos e entorpecentes, o acusado teria confessado a prática do tráfico, porém, em solo policial preferiu o silêncio.

Notificado o acusado, fora apresentada defesa prévia a fls. 118/119 e recebida a denúncia em 27 de maio de 2022 (fls. 121/124).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas e o acusado foi interrogado. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa requereu a nulidade da busca pessoal, condução e prisão do acusado realizada pela Guarda Civil Municipal, por afronta ao art. 144, §8º, da Constituição Federal, com a absolvição do acusado; subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, levado em consideração a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11343/06, fixando-se o regime aberto para cumprimento, sem prejuízo da substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.

É o breve relatório. DECIDO.

Preliminarmente, incabível o acolhimento da nulidade arguida pela Defesa, porquanto não há qualquer ilegalidade na busca pessoal, condução e prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Com efeito, o artigo 301 do Código de Processo Penal permite a qualquer pessoa prender em flagrante quem esteja praticando um delito. A propósito, o tráfico de drogas, delito imputado ao acusado, é crime permanente. Desta forma, o estado de flagrância se perpetua no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse sentido vem decidido este E. Tribunal Bandeirante:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Não ocorrência. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Reprimenda bem dosada. Regime aberto para o início do cumprimento da pena fixado de maneira adequada. Primariedade do acusado, quantum de pena e circunstâncias concretas que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501118-62.2019.8.26.0618; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)

Igualmente é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". (...) 8. Habeas corpus não conhecido. 2 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO (...) 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes

destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não conhecido. HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015. negritei

De mais a mais, anote-se que não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que a abordagem foi motivada pelo nervosismo do acusado diante da aproximação da viatura, tendo a suspeita encontrado azo no comportamento de Luciano, tendo ele próprio confessado a prática delitativa, informalmente e em juízo, admitindo que estava no local exercendo o tráfico. Portanto, fica afastada a alegação de ilicitude da prova decorrente das diligências efetuadas pelos guardas municipais sem prévia comunicação do fato às Polícias Civil e Militar.

Em seguimento, passo à análise do mérito da lide.

A pretensão punitiva é procedente.

Há nos autos prova dos fatos e da autoria.

A materialidade do delito está bem provada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termos de depoimentos (fls. 03/05), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), fotos (fls. 19/22), laudo de exame químico toxicológico positivo para substância entorpecente (fls. 23/26, 84/86), relatório de investigações (fls. 87/88), além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, está ratificada, diante dos depoimentos colhidos em juízo, bem como da análise de todo o conjunto probatório.

O guarda municipal DIEGO IVALDO DE SOUZA disse que estavam patrulhando pelo bairro Campo dos Alemães e na avenida avistaram o rapaz com uma sacola, se assustou e largou a sacola e saiu correndo, acharam estranho e foram abordá-lo. Ele confessou que tinha acabado de pegar o saco para vender. ele não deu mais detalhes. Ele falou que foi um rapaz de bicicleta que deixou para ele. Ele falou que tinha acabado de chegar ali, fazia poucos minutos que ele estava ali. Não disse que frequência estava no tráfico, e ele tinha comentado até terminar de vender o tucho, a sacola inteira. Só tinha as drogas na sacola. Não se lembra das anotações mencionadas. Não tinha dinheiro em espécie. Assim que ele avistou a viatura ele começou a correr com a sacola nas mãos. E aí ele lançou a sacola e continuou a correr. Não mencionou nada sobre o turno.

Seu colega de farda, FELIPE DE LIMA MAGACHO, deu um depoimento no mesmo sentido. A equipe estava em patrulhamento, próximo ao "PEV", no Campo do Alemães, e ele, ao avistar a equipe começou a empreender fuga. Foi acompanhado e abordado. Quando foi abordado, estava com uma sacola, e em breve entrevista disse que estava na prática do tráfico. Na sacola tinha maconha, pinos de cocaína, não se lembra se havia anotações escritas. Na ocasião, tinha mencionado que tinha acabado de pegar outro rapaz, e que ele estava começando o turno naquele momento. Ele falou que tinha acabado de pegar a sacola. Ele falou que estava havia pouco tempo na traficância. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. É ônus da defesa demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, o qual não se desincumbiu. Confira-se, a respeito, C. STJ. 5ª Turma, HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017. Ainda, um excerto deste E. Tribunal:

"Apesar das insurgências da D. Defesa, cumpre ponderar que não há qualquer razão séria para desprestigiar as palavras dos policiais ouvidos como testemunhas. Primeiro porque nada foi comprovado contra eles. Segundo, porque suas versões são

claras, serenas, harmônicas e coerentes. Terceiro, porque sequer conheciam o apelante. Quarto, porque não há qualquer motivo demonstrado de que tivessem qualquer razão espúria para prejudicar o apelante, imputando-lhe, falsamente, um crime. Quinto, porque são servidores do Estado e têm dever legal de agir conforme os ditames da correção. Sexto, porque suas versões guardam contornos de verossimilhança. Sétimo, porque desprestigiar os depoimentos de servidores públicos apenas porque o são ou porque efetuaram a prisão, seria clara manifestação de preconceito profissional, que não encontra guarida na lei ou no Direito.” (TJSP, Apelação nº 005820-31.2013.8.26.0297 Jales, 2ª Câm., relator Desembargador ALEX ZILENOVSKI, j. 18.8.2014)

Interrogado, LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO tem 28 anos, tem mulher sem filhos, tem duas enteadas, a casa da mãe dele é na Rua Cristiano Pugliesi, 233, Campo dos Alemães, a mulher tem uma casa na Rua 83, trabalhava como ajudante de pedreiro, ganhava por dia R\$ 80,00. Sem passagens criminais. Confessou a traficância. Disse que um colega dele o chamou para vender drogas. Ele sempre falava que não; mas ele foi nessa vez. Prometeu uma porcentagem, era de três reais o lucro do pino, não deu tempo de vender nada. Iam vender o pino, e ele ia vender as outras drogas. Não tinha turno, era até vender tudo.

A prova reunida nos autos é coesa e indica com segurança que o acusado estava, de fato, praticando o tráfico de drogas, tendo ele próprio admitido a prática delitiva. Sendo assim, registra-se que a confissão judicial do acusado é apta a fundamentar sua condenação, especialmente porque corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial pelo auto de exibição e apreensão, fotos, e laudo de exame químico toxicológico positivo para substância entorpecente.

Outrossim, não há qualquer ilegalidade na abordagem, conforme já dito no enfrentamento da preliminar arguida, tendo os guardas civis municipais surpreendido Luciano na posse de variada quantidade de entorpecentes, prontos para venda, fato este consistente na prática do crime testemunhado no art. 33, caput, da Lei nº 11343/06. Assim, de rigor a prolação de édito condenatório.

Passo a dosar a pena.

Pena-base: considerando-se os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, denoto que o réu agiu com a reprovabilidade inerente ao delito; não possui maus antecedentes; nada tendo a se valorar sobre a conduta social e personalidade; os motivos do delito já estão punidos pela própria tipicidade e previsão legal; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não havendo o que considerar; nada se apurou de concreto sobre as consequências do delito. A natureza e quantidade das drogas encontradas, todavia, chama a atenção, sendo 270 porções de cocaína, 121 porções de crack, subproduto da cocaína, e 77 porções de maconha. A potencialidade destrutiva desse material é imensa e merece uma represália à altura. Por fim, o delito de tráfico de drogas é crime vago e não há vítima determinada, de modo que não se pode valorar negativamente qualquer comportamento da parte passiva, pois aqui a vítima é a saúde pública, afetando-se, indiretamente, a sociedade, ante o tráfico fomentar a prática de outros ilícitos. Assim, majoro a pena na fração de uma terça parte, passando a pena base ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa

Agravantes e atenuantes: Luciano confessou, motivo pelo qual a reprimenda atenua-se em $\frac{1}{3}$: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Causas de aumento e diminuição da pena: o acusado é primário (fls. 27/29) e não ostenta antecedentes criminais. No entanto, há indícios de que Luciano se dedique a atividades criminosas, em especial à venda de drogas: além das diversas naturezas e razoáveis quantidades de drogas (elementos já considerados em primeira fase e desprezados aqui, em terceira), com Luciano foi encontrada uma anotação com contabilidade do tráfico. Essa anotação se extrai do auto de apreensão de fls.

10/11. Além disso, há a admissão por parte dele de que atuava para outros traficantes, com a obrigação de vender tudo e com remuneração baseada em uma parcela das vendas. Esses elementos são muito importantes e demonstram que a venda não é esporádica, mas sim rotineira. Há, portanto, dedicação à venda espúria. E o

reduzidor não se aplica a situações como as de Luciano. Por isso, sem qualquer reduzidor, a pena estabiliza-se em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o quantum não permite e porque entendo que seja insuficiente para atingir as finalidades da pena (art. 44, inciso III, do CP). Pelo mesmo motivo, não concedo o benefício previsto no art. 77 do Código Penal.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, consideradas a quantidade e natureza de drogas apreendidas com Luciano. O C. STF permite a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo quantum com amparo na natureza e quantidade de drogas. Confira-se: "É legítima a fixação de regime inicial semiaberto, tendo em conta a quantidade e a natureza do entorpecente, na hipótese em que ao condenado por tráfico de entorpecentes tenha sido aplicada pena inferior a 4 anos de reclusão. A valoração negativa da quantidade e da natureza da droga representa fator suficiente para a fixação de regime inicial mais gravoso. STF. 2ª Turma. HC 133308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/3/2016 (Info 819)". Outro aresto, sem prejuízo de múltiplos outros: "(...) 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. 2. Como o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e quantidade da droga, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. (...) STF. 2ª Turma. HC 131887, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02/02/2016."

ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO, devidamente qualificado nestes autos, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, na diária mínima, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Luciano não poderá apelar em liberdade, pois não houve alteração fática nos elementos que justificaram sua prisão preventiva. Ainda mais agora, com a prolação desta sentença condenatória. Recomende-se, com a observação de que Luciano poderá ser transferido para o regime semiaberto, aqui determinado.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos e determino a destruição das drogas, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06. Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário.

Deixo de aplicar o previsto no §2º, do art. 387, do CPP, por entender que cabe ao juízo da execução a análise da pena já cumprida, para fins de detração penal e progressão do regime prisional, até mesmo porque se desconhece o requisito subjetivo neste momento (bom comportamento carcerário), motivo pelo qual seja prudente a análise desse dispositivo em sede executiva.

Condeno, ainda, o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da legislação vigente, observada a gratuidade de justiça, caso concedida em outra oportunidade.

Transitada em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive, à Justiça Eleitoral, anotando-se que a inscrição dos nomes dos acusados no rol dos culpados foi abolida pelas normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado (art. 372, caput).

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

São José dos Campos, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA